

第 46 問

甲（25歳・男性）は、Aの家に立ち入って、金員を奪おうと考え、A宅の前まで赴いた。Aが、昼間は自宅を留守にしていること、その際鍵を閉め忘れていることが多いことを知っていた甲は、Aに遭遇することなく金員を奪えるだろうと思っていたが、万が一、逃走時にAに遭遇した場合には、ナイフを用いて脅そうと考え、ナイフを懐に忍ばせていた。

甲は、午後2時40分頃、A宅へ向かったところ、案の定、Aはこの日も鍵を閉め忘れて外出していた。甲がA宅に立ち入ったところ、人のいる気配がなかったため、金目の物がないか、A宅の筆筒などを開けていった。

すると、午後2時45分頃、甲がA宅に入っていったのを目撃し、不審に思ったため、様子を見に来たAの隣人であるB（60歳・女性）が、A宅を物色している甲を見付け、「何をやっているの。」などと怒鳴りながら、甲に近付いてきた。甲は、まだ何も盗っていなかったが、ここで捕まったら元も子もないと思い、Bから逃げようと思い、同人の顔面を手拳で数回殴打し、同人が倒れた隙を見てA宅から逃げ出した。なお、この時、甲はBに犯行を発見されたことに驚き、ナイフを所持していたことを忘れていた。

起き上がったBは、甲を捕まえようと思い、100メートルほど走って追いかけたが、甲を見失ってしまった。そのため、甲を捕まえるのを諦め、Aが戻ってくるまでA宅で待機することとした。

甲は、A宅から200メートルほど離れた自宅へ戻った後、Bに顔を見られたことから、警察に通報され、逮捕されたりしないか不安になった。そこで、午後3時頃、甲は、BがA宅で待機している場合には、同人を殺害しようと意を決してA宅へ向かった。甲がA宅の玄関から中の様子をうかがっていると、A宅からBが出てきて、「泥棒よ。誰か来て。」と大声で叫んだので、甲は所持していたナイフでBを突き刺し、出血多量により同人を死亡させた。

なお、甲とBとの間に面識はなかった。

甲の罪責について、論じなさい。

第1 ナイフを準備した行為

まず、逃走時にAに遭遇した場合のために、ナイフを用意している点については、事後強盗の予備の成否が問題となる（**論点** 事後強盗の予備）。

この点について、判例は、「刑法237条にいう『強盗ノ目的』には、同法238条に規定する準強盗を目的とする場合を含むと解すべきである」として、肯定説に立っている（最決昭54.11.19）。

※ 第3の行為について、事後強盗殺人罪を成立させている場合には、事後強盗の予備を論じる実益はない。一方で、その成立を否定した場合には、第2の行為については甲が同ナイフの存在を失念しており、同ナイフは用いられていないのだから、事後強盗の予備を論じる実益が生じる（第4の罪数も参照）。

総合 211 頁 論証 93 頁

第2 A宅に侵入し、筆筒などを開けた行為～Bを殴打した行為

1 甲がA宅に立ち入った点について、住居侵入罪（130前段）が、筆筒などを開けていった点に、窃盗未遂罪（243、235）が成立することは明らかである。

2 そして、「窃盗」（238）とは、既遂・未遂を問わないとするのが判例であるから（大判昭7.12.12）、Bから逃げようと思い、同人の顔面を手拳で数回殴打した行為には、事後強盗罪（238）の成否を検討することになる。

まず、「暴行又は脅迫」に当たるかは、相手方の反抗を抑圧するに足るものである必要があるため、問題文の事情を指摘しながら、認定することが求められる（**論点** 事後強盗罪における暴行・脅迫の程度 **予R4**）。また、「暴行又は脅迫」が加えられる相手方は、必ずしも窃盗の被害者であることを要しない（大判昭8.6.5）。

総合 208 頁 論証 91 頁

「暴行又は脅迫」を認めた場合、事後強盗罪の既遂・未遂は、窃盗の既遂・未遂をもって区別するのが判例である（最判昭24.7.9（未遂）、大判昭7.6.9（既遂））から、本問では事後強盗未遂罪が成立することになる（**論点** 事後強盗罪における既遂・未遂の区別 **予R4**）。

総合 209 頁 論証 91 頁

なお、窃盗の既遂・未遂をもって区別するという判例の立場といわゆる身分犯説は整合しないという指摘があるが、下級審判例には、身分犯説をとるものもあり（真正身分犯説をとるものとして大阪高判昭62.7.17【百選Ⅰ95】、不真正身分犯説をとるものとして東京地判昭60.3.19）、この論理関係についてはあまり意識されていないようである。

第3 Bを刺殺した行為

次に、甲が、A宅に戻りナイフでBを突き刺し、殺害した行為であるが、この行為が窃盗の機会に行われたものであれば、事後強盗殺人罪が成立することになる（最決平14.2.14、最判平16.12.10【百選Ⅱ43】参照）（**論点** 窃盗の機会 **予R4**）。一方で窃盗の機会性を否定すれば、殺人罪（199）が成立するに止まる。

総合 211 頁 論証 93 頁

この点について、本問類似の事案において裁判例（東京高判平17.8.16）は、「被告人は、被害者側の支配領域から完全に離脱したと

いふべきであるから、被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況がなくなったと認めるのが相当である」として、これを否定しているから、ここでも否定の方がよいだろう（もっとも、上記裁判例の原審では肯定されているから、肯定するという結論も十分にあり得るところである。）。

※ この点について、すでに甲には（事後）強盗（未遂）罪が成立していることから、強盗殺人罪（240後段）の成否を問題とすることもできる。このような構成を採った場合、強盗の機会性を論じることになるだろう。

第4 罪数

甲には、①事後強盗予備罪（238、237）、②住居侵入罪（130前段）、③窃盗未遂罪（243、235）、④事後強盗未遂罪（243、238）、⑤殺人罪（199）が成立し、③は重い④に吸収され、②と牽連犯（54 I 後段）になる。

問題は①と④の関係で、通常予備罪は、連続性のある未遂罪・既遂罪と吸収関係にあるが、本問では、第2の行為の時点ではナイフの存在を失念しているので、連続性があるといえるか疑問がある。仮に、連続性を否定するのであれば、併合罪（45前段）として処理するのがよいだろう。一方で、連続性を肯定するのであれば、①は④に吸収されることになる。

答案構成

第1 ナイフを準備した行為

1 事後強盗罪（238）の予備罪（237）

↓

2 肯定説

↓

3 事後強盗罪の予備罪が成立する

第2 A宅に侵入し、筆筒などを開けていった行為

住居侵入罪（130前段）及び窃盗未遂罪（235、243）成立

第3 Bから逃げようと思い、同人の顔面を殴打した行為

1 事後強盗罪（238）

↓

2 「窃盗」は、未遂でもよい

↓

「逮捕を免れ」

↓

窃盗の機会

↓

「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要がある

↓

あてはめ

↓

3 事後強盗罪は未遂にとどまる

第4 Bを刺殺した行為

1 事後強盗罪が成立する場合には強盗殺人罪の成立も認められる（240後段）

↓

2 窃盗の機会性

↓

窃盗犯人に対する追及が継続していたか否かで決すべき

↓

あてはめ

↓

3 殺人罪（199）が成立する

第5 罪数

①事後強盗予備罪、②住居侵入罪、③窃盗未遂罪、④事後強盗未遂罪、⑤殺人罪が成立する。③は④に吸収される。②④は、牽連犯（54 I 後段）となる。

①、④及び⑤は併合罪となる（45前段）

第1 ナイフを準備した行為

1 Aに遭遇した場合に備えて、ナイフを用いて脅そうと考え、ナイフを
 2 懐に忍ばせていた行為について、「強盗の罪を犯す目的で、その予備を
 3 した」ものとして、事後強盗罪（238条）の予備罪（237条）の成
 4 立が考えられる。

5
 6 2 この場合、脅すか否かは確定的でない。しかし、見つかった場合に脅
 7 す意思是確定的であり、いうならば脅すか否かが条件にかからしめられ
 8 ているにすぎない。

9 事後強盗は強盗をもって論ずる（238条）ことからしても、事後強
 10 盗罪についても予備罪を成立し得るというべきである。

11 3 したがって、事後強盗罪の予備罪が成立する。

第2 A宅に侵入し、筆筒などを開けていった行為

12 窃盗目的でかかる行為に及んだ点については、「正当な理由がないの
 13 に、人の住居……に侵入し」たものとして、住居侵入罪（130条前
 14 段）が成立する。

15 かかる行為によって財物の占有移転の現実的具体的危険が生じている
 16 といえるから、「他人の財物」の「窃取」に「着手」したとして、窃盗
 17 罪（235条）の実行の着手（43条本文）が認められる。

18 したがって、窃盗未遂罪（243条）が成立する。

第3 Bから逃げようと思い、同人の顔面を殴打した行為

19 1 かかる行為について、事後強盗罪（238条）の成立が考えられる。

20 2(1) 「窃盗」（238条）は、未遂でもよい。本罪は事後強盗罪の人身

1

1 犯たる性格に着目して重罰に処すものだからである。上記のように、
 2 本問では、甲は窃盗の実行に着手しているから、この要件は満たす。

3 そして、甲はBの逮捕から逃れる目的で上記行為をしているから、
 4 「逮捕を免れ」の要件を満たす。また、後述のように、事後強盗罪が
 5 成立するためには記述されざる構成要件要素として窃盗の機会性が必
 6 要となるところ、ここではこの要件も認められると考えてよい。

7 (2) 次に、「暴行又は脅迫」の要件について検討する。

8 事後強盗罪は強盗として評価されるものであるから、事後強盗罪に
 9 おける暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を抑圧する程度のものであ
 10 る必要がある。なお、暴行又は脅迫の相手方は、窃盗の直接の被害者
 11 に限られない。

12 まず、甲は25歳の男性であるのに対し、Bは60歳の女性である
 13 から年齢差・体力差がある。また、A宅には甲とB以外の人間はいな
 14 かったものと考えられるので、Bが誰かに助けを呼ぶことができるよ
 15 うな状況でもない。さらに、甲はBの顔面という人体の枢要部を狙
 16 い、Bが倒れるほどの力をもって暴行を加えている。

17 これらの事実からすれば、上記程度の「暴行」を加えていると評価
 18 することができる。

19 以上から、甲には事後強盗罪が成立する。

20 3 ただし、事後強盗罪は未遂にとどまると解すべきである（243
 21 条）。通常の強盗罪の既遂・未遂の判断基準は、財産取得の有無に
 22 よって判断されるところ、これに準ずる事後強盗罪のそれもやはり強盗

2

の場合と同様でなければならないからである。

第4 Bを刺殺した行為

1 この行為についても、事後強盗罪（238条）の成立可能性がある。
 2 甲には殺意があるから、事後強盗罪が成立する場合には強盗殺人罪の成
 3 立も認められる（240条後段）。

2(1) この点について、甲は上記行為の後に一度自宅に戻り、再びA宅に
 4 向かった後、Bを刺殺している。そうすると、上記窃盗との結び付き
 5 が弱く、これを事後強盗として評価することはできないのではない
 6 か。

(2) 事後強盗は強盗として扱われるところ、強盗罪における暴行・脅迫
 7 が財物奪取の手段として行われる必要があることとの均衡を図らなけ
 8 ればならない。

したがって、条文上明らかではないが、事後強盗罪における暴行・
 9 脅迫は、窃盗の機会に行われる必要がある。

そして、窃盗の機会に行われたといえるか否かは、時間的場所的接
 10 着性などを基礎に、窃盗犯人に対する追及が継続していたか否かで決
 11 すべきである。窃盗犯人に対する追及が止んだ場合は、窃盗と暴行・
 12 脅迫との関連性が弱く、全体として観察したときに強盗と評価するこ
 13 とが難しいからである。

(3) 本問では、確かに、A宅から甲の自宅までは、200メートルと比
 14 較的近接した場所的關係にある。また、甲がA宅を出てから再び戻っ
 15 てくるまでに約15分間しか経過しておらず、時間的にも近接してい

3

る。また、甲がA宅に戻ったのは、Bに顔を見られたことから、警察
 16 に通報され、逮捕されることを免れるためである。そうだとすれば、
 17 当初の窃盗と動機の点において連続性が認められる。

しかし、Bは甲を見失ってしまい、捕まえるのを諦め、A宅に戻っ
 18 ているし、甲も一旦自宅に戻っている。そして、甲とBには面識がな
 19 いから、Bが甲宅をつきとめて甲を逮捕することは不可能となってい
 20 るといえる。そうだとすれば、甲はBの支配領域から離脱しており、
 21 甲に対する追及可能性は消滅したものと評価すべきである。

したがって、窃盗の機会性は認められない。

3 以上から、甲には事後強盗罪（強盗殺人罪）は成立せず、「人を殺し
 22 た」ものとして、殺人罪（199条）が成立するにとどまる。

第5 罪数

以上より、甲には①事後強盗予備罪、②住居侵入罪、③窃盗未遂罪、
 23 ④事後強盗未遂罪、⑤殺人罪が成立する。③は重い④に吸収される。②
 24 ④は目的手段の關係にあるから、牽連犯（54条1項後段）となる。

①は連続性のある④に吸収されるようにも思えるが、甲はA宅でBに
 25 暴行を加えた際には、ナイフの存在を失念し、これを用いていない。し
 26 たがって、①と④に連続性はなく、併合罪となると解すべきである（4
 27 5条前段）。

⑤とも併合罪となる。

以上

4